

1500398-98.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas de longa data - fls. 38/126. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como as porções estavam divididas e armazenadas, afigura-se quadro seguro a apontar que seriam destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500398-98.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500398-98.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SILVA DORNELAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALESSANDRO CORREA LEITE

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RAFAEL SILVA DORNELAS, qualificado às fls. 05/06, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2022, de madrugada, na Rua Renê Antônio Sanches, n.º 80, bairro Conjunto Habitacional Mário Amato, e na chácara localizada próxima à Rodovia Júlio Budiski, SP-501, km 7,8, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, RAFAEL SILVA DORNELAS, qualificado às fls. 05/06, mantinha em depósito 01 (um) papelote contendo 5.90 gramas (cinco gramas e noventa decigramas) de maconha, 01 (um) papelote contendo

4,40 gramas (quatro gramas e quarenta decigramas) de maconha, 05 (cinco) papelotes contendo 3,10 gramas (três gramas e dez decigramas) de cocaína e 35 (trinta e cinco) papelotes contendo 23,00 gramas (vinte e três gramas) de cocaína, com o fim de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, fotografias de fls. 23/27 e laudos periciais de fls. 175/181. Segundo apurado, o denunciado adquiriu as substâncias entorpecentes acima mencionadas de pessoa desconhecida e as manteve em sua residência e em uma chácara localizada no endereço acima mencionado para posterior revenda a dependentes químicos. Já tendo ciência do prévio envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas em razão de ocorrências pretéritas, a Polícia Judiciária representou pela expedição e mandado de busca e apreensão em detrimento do denunciado, nos dois endereços indicados acima e, em cumprimento aos mandados, policiais civis realizaram minuciosa busca na residência localizada na Rua Renê Antônio Sanches, n.º 80, onde localizaram na cozinha 01 (um) papelote contendo 5.90 gramas (cinco gramas e noventa decigramas) de maconha. Prosseguindo nas diligências, os policiais rumaram em direção a chácara ocupada por RAFAEL contando com o auxílio de cães farejadores, onde localizaram na sanca de gesso do dormitório 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, embaladas em sacos plásticos, fracionadas em condições de pronta venda, totalizando a quantia de 23.0 (vinte e três) gramas; bem como no interior do guarda roupas, em um isopor, uma porção de maconha, pesando 4.4 gramas (quatro gramas e quarenta decigramas) e 05 (cinco) porções de cocaína, pesando 3.1 (três gramas e dez decigramas), também embaladas da mesma forma que as demais encontradas anteriormente e em condições de pronta venda. O denunciado foi preso em flagrante. Há notícia nos autos no sentido que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas de longa data - fls. 38/126. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como as porções estavam divididas e armazenadas, afigura-se quadro seguro a apontar que seriam destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 244), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 250), o despacho de fls. 252/255, de 11 de agosto de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 317/324), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu ppor tráfico de drogas conforme descrito na denúncia. Por sua vez, a ilustre Dr.^a Defensora (fls. 329/348), requer o reconhecimento do bis in idem em razão do princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato, já que as mensagens do laudo pericial se referem ao Processo nº 1500039-51.2022.8.26.0583 em que o réu foi preso e condenado pelo mesmo crime a ele imputado nestes autos, portanto, refere-se a crime único, pois praticado em pequeno intervalo de tempo, pois como o réu mesmo disse, os entorpecentes encontrados em sua chácara era da época da sua primeira prisão, ou, alternativamente, pela desclassificação do crime de tráfico de droga para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28, da Lei n 11.343/06, e assim, deve ele ser absolvido da imputação de tráfico de drogas por inexistir provas suficientes a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, CPP, ou pela desclassificação do delito para porte de drogas. Subsidiariamente, em caso de condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pelo afastamento da hediondez do delito, e eleição do regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda. É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante

provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 19/22; pelas fotografias de fls. 23/27; pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 38/79 e 214/234; pelo relatório de investigação policial de fls. 80/126; pelo laudo pericial de objetos de fls. 175/177, que analisou - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0268) Descrição:

Um invólucro(s) encerrando onze sacos plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip"). Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0269)

Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando um caixa de isopor sem tampa, com inscrições ""panpharma", "Retornar", "caixa de isopor e gelo" "AGRADECEMOS" e uma etiqueta de cor laranja com inscrições. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo químico toxicológico de fls. 178/181, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0027006)

Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 8,04 grama(s) - Oito gramas quatro centigramas. Massa Líquida: 5,5 grama(s) - cinco gramas cinquenta centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA

presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0027007) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade:

6,37 grama(s) - Seis gramas trinta sete centigramas. Massa Líquida: 4,03 grama(s) - Quatro gramas três centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), Item 3 (Acondicionado sob o lacre 0027008)

Descrição: Cinco invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 5,39 grama(s) - Cinco gramas trinta nove centigramas. Massa Líquida: 1,86 grama(s) - Um grama oitenta seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA

presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), Item 4 (Acondicionado sob o lacre 0027009)

Descrição: Trinta cinco invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 26,68 grama(s) - Vinte seis gramas sessenta oito centigramas. Massa Líquida: 14,91 grama(s) - Quatorze gramas noventa um centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia

em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha André Luiz Zanadrea, investigador de polícia, sob o crivo do contraditório declarou que Rafael foi preso pela Delegacia de Entorpecente em janeiro deste ano, portando uma certa quantidade de cocaína que iria comercializar. Seu celular foi apreendido e ficou demonstrado que ele fazia intenso comercio de entorpecentes, bem como ter ele uma chácara onde guardava as drogas e arma de fogo, pelas fotos tiradas com o celular do réu. Coube investigar a referida chácara, conseguindo localiza-la próximo a empresa Leite Líder, e foi solicitado mandado de

buscar para averiguação. No dia 11 de maio cumpriu mandado de buscas na chácara enquanto outros policiais foram cumprir mandado em sua residência. Disse que foi necessário arrombar o portão para ingressar na chácara e lá encontraram restos de comida, petrechos para alimentação e restos de carne na churrasqueira, cerveja, refrigerante, local que era normalmente utilizado pelas pessoas. No forro do gesso da sala, perceberam que havia um saco plástico e ao alcança-lo, constatou que havia 35 porções de cocaína embaladas em saco "zip", bem como mais dessas embalagens vazias. Na mesma casa, no quarto, encontrou um demonstrativo de pagamento em nome do réu, onde demonstrou que ele habitava e frequentava aquele local, junto a este demonstrativo, foi encontradas outras duas porções de maconha e mais 5 porções de cocaína embaladas em saco "zip", bem como uma espingarda de pressão e caixas de munição(chumbinho), carregador de revolver, vazio. Diante disso, avisaram outra equipe que efetuara a prisão do Rafael que foi conduzido e preso em flagrante. Afirma que foi utilizado o cão farejador do BAEP para localização das drogas, já que não tinham conhecimento onde ele guardava as drogas. Afirma que no dia 7 de janeiro ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e saiu em liberdade na audiência de custódia. Não sabem o dono exato da referida chácara, mas identificou as pessoas pelos carros que lá estavam e um deles estava em nome do pai de Rafael e pelo comprovante de pagamento do próprio Rafael que estava na chácara. Não foi identificadas outras pessoas que frequentam o local, pois é um lugar afastado e não há vizinhança, inclusive a chácara é murada. A primeira prisão do réu, dia 7 de janeiro, ele portava 50 gramas de cocaína também, e estavam dentro de um saco plástico branco. Havia uma porção maior em saco plástico branco, e outra fragmentada pronta para ser separada.

A testemunha Jorge Ribeiro Camilo, é papiloscopista policial, sob o crivo do contraditório declarou que integrou a equipe que efetuou diligências na casa do réu, e chegando lá, ele estava acordado e acompanhou as buscas na residência onde foi localizada na cozinha do imóvel, certa porção de maconha. Fez análise do celular do réu quando da sua prisão em 11 de janeiro. Da análise no celular havia muitas mensagens, nos metadados das fotografias, que tinha droga enterrada e que naquele dia não poderia desenterrar, pois havia pessoas no local, somente no outro dia poderia desenterrar. No cumprimento do mandado de busca na casa do réu, o próprio Rafael perguntou se tinham ido fazer diligências na chácara. Quanto a perícia elabora no celular foi quando da primeira prisão do réu realizada em dois celulares, um iPhone e um Samsung, o iPhone não foi periciado porque estava bloqueado, e a análise foi feita somente no segundo celular, e dessa última prisão não sabe se conseguiram desbloquear o aparelho dele, e que ainda não havia retornado o laudo. A primeira prisão do réu foi no dia 7 de janeiro, e não participou dessa diligência. No dia 11 de maio foi até a residência na Rua Antonio Sanches, 80, Mario Amato, salvo engano, e não sabe se é a mesma que ele morava em janeiro. Quanto à chácara, foi constatado que era do réu, pois já tinham informações de inteligência que ela era utilizada e no celular havia fotos com metadados da localização nessa chácara. Não levantou quem era o proprietário da chácara, e que tinha muitas fotos dele em festas e reuniões de amigos na chácara. Afirma que não apuraram quem era o verdadeiro proprietário e nem a que título ele frequentava aquele lugar.

O réu Rafael Silva Dornelas, em seu interrogatório declarou que é a primeira vez que foi preso. Sobre os fatos disse que a maconha encontrada em sua casa era para seu próprio uso, e a cocaína encontrada na chácara também era sua, mas que se refere ao primeiro processo que já foi julgado por este Juízo. Deixou a droga na chácara que sobrou daquele primeiro processo, para uso e para eventual venda a alguns conhecidos que frequentava juntos, amigos na chácara e como o policial disse, nos churrascos que realizava. Saiu no sábado e já começou a trabalhar na segunda-feira com esquadrias de alumínio na Metal Master até o dia da sua prisão. Afirma que na época usava maconha e cocaína, na época dessa prisão. Fazia uso somente em eventos e festas que realizava na chácara. Afirma que fornecia para os amigos pelo preço que pagava na droga nos churrascos que realizava, usavam juntos na hora do churrasco. Está arrependido. Disse que levou as drogas para chácara antes da sua primeira prisão, deixou lá depois de tirar uma parte para vender,

quando foi preso, e sobrou essa quantidade que ficou lá e não saiu mais, e a outra porção era para seu uso e foi encontrada em sua residência. Afirmo que a maconha encontrada na chácara no quarto era para seu uso, um pedacinho que sobrou e tinha em sua casa. A chácara é de sua pai que comprou após a venda de um sítio, mas estava na sua posse, pois seu pai raramente vai até a chácara. Encerrando-se a instrução processual.

Em se tratando de confissão qualificada, o réu expôs motivos e justificativas para a prática do crime, agregando teses defensivas discriminantes e exculpantes da sua culpabilidade, inclusive admitindo que apenas consumia com amigos, que lhes dava pelo preço que pagou e que usavam juntos, de forma recreativa, o que não se pode acolher, porque destoa de toda a prova dos autos, embora admite que toda a droga lhe pertença.

Nesse sentido é a jurisprudência a respeito do tema:

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). ABOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA E DOLO. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. (ART. 29, § 2º, DO CP). CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restando devidamente comprovada a conduta dolosa da ré, imperativa a condenação pelo crime de estelionato. 1.1. No caso, a vítima esclareceu de forma robusta o modus operandi e o fato da ré ter se apresentado com outro nome, o que evidencia o seu dolo de ludibriar. 2. É evidente no presente caso a divisão de tarefas e a contribuição efetiva da ré para a prática do delito, pois foi a ré/apelante que compareceu ao local marcado demonstrando tratar-se de uma negociação normal, ou seja, sua ação está incluída dentro do conceito de meio fraudulento, portanto, não pode ser tida como de menor importância a justificar a aplicação do art. 29, § 2º, do CP. 3. A confissão qualificada no presente caso não justifica a atenuante pelos seguintes fundamentos: a) a confissão que não reflete a veracidade não tem o condão de atenuar a pena; b) considerar uma confissão qualificada baseada em tese inverídica gera subversão do próprio sistema de dosimetria; c) se a confissão está estribada em mentira, evidente a inexistência de arrependimento ou contribuição para a verdade dos fatos, não podendo o réu se beneficiar de sua própria torpeza. 3.1. No caso a ré confirmou os fatos, mas disse não saber estar contribuindo para o crime, o que foi rejeitado diante da comprovação de que usou nome falso." (Acórdão 1099941, 20170110363428APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018).

Estando a confissão em dissonância com a prova dos autos, não é possível acolhe-la, embora tenha admitido que fornece a droga aos amigos, ainda que de forma recreativa, porém, em momento algum admitiu que vende a droga como meio de subsistência, tentou de todas as formas se esquivar da grave acusação que lhe pesa. Assim, ao contrário do afirmado pela defesa em sede de alegações finais nos autos há prova suficiente e segura a demonstrar não só a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, mas também a autoria deles pelo réu e de que inexistente qualquer causa que possa levar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, entretanto, há importantes considerações a se fazer.

E os demais elementos de prova dos autos confirmam a conduta delituosa do réu, aliás, foi preso pelos Policiais Civis em cumprimento de mandado de prisão, decorrente de uma investigação que se originou da primeira prisão em flagrante delito do réu, quando foi surpreendido portanto certa quantidade de droga que venderia no ponto combinado com dois indivíduos e que naquela oportunidade, não foi realizadas diligências na chácara do genitor do réu, pois os policiais não tinha a exata localização, apenas após várias diligências e investigações, descobriram onde se localizava, e meses depois da sua primeira prisão, houve cumprimento de mandados de buscas domiciliar na residência e na chácara do réu, onde fora localizada grande quantidade de cocaína e porções de maconha, e segundo o investigado André, a droga estava escondida na sanca de gesso da sala da casa na chácara, além de porções de maconha que também foram encontradas na residência do réu por outra equipe. Além disso, André Zanandrea também disse que foi necessário o auxílio do cão farejador do BAEP para tentativa de localização de drogas, pois não tinha informações

precisas onde o réu mantinha em depósito as drogas. Também afirmou que um demonstrativa de pagamento foi encontrado na residência da chácara com o nome do réu.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (02 porções de maconha pesando 10,3 gramas e mais 5 papелotes de cocaína pesando 3,10 gramas e 35 papелotes de cocaína pesando 23 gramas), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

De fato, o réu mantinha em depósito e guardava para fins de destinação a terceiros usuários, maconha e cocaína, conforme encontradas e relatadas fielmente pelos policiais civis que cumpriram os mandados de busca e apreensão domiciliar na casa e na chácara do réu. Impossível crer que a droga encontrada na chácara estava lá desde a sua prisão em janeiro deste ano, já que é clara e evidente que após sair da prisão, continuou com a prática espúria do comércio de drogas.

Também não prospera a alegação de que a droga era apenas para seus consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que após a sua primeira prisão, durante as investigações baseadas no aparelho celular do réu, descobriram que ele vinha se dedicando ativamente ao tráfico de drogas no local.

Ademais, o desencontro das versões apresentadas pelo réu, acaba se confundindo entre ele, justamente porque não encontram justificativas para tamanha quantidade de droga, os demais objetos usados para embalar drogas, encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, nem mesmo a versão de que a droga era consumo eventual com amigos, em churrasco não convence, embora tenham sido localizados restos de comida e bebida na chácara, porém, por vezes, os traficantes utilizam esses locais afastados para produzir festas e eventos onde são livremente fornecidos entorpecentes para os frequentadores, portanto, sua versão é fantasiosa e desconexa do conjunto probatório coligido aos autos.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu nos imóveis onde foi surpreendido.

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 23/27, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar sua versão ofertada em Juízo.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa dos réus e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu, até porque logo após sair da prisão, no mês de janeiro deste ano, novamente foi preso com grande quantidade de drogas em seus imóveis.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar que a droga encontrada na chácara do réu, não se refere ao primeiro fato cometido em janeiro deste ano, quando foi preso em flagrante delito em via pública, no momento em que entregaria droga para dois compradores, inclusive, policiais tinha informações na época que o réu guardava drogas em uma chácara, porém, desconheciam a sua localização, e o réu não forneceu qualquer indicação de onde se localizava tal chácara, nem mesmo forneceu a senha de seu celular iPhone, o qual não foi possível desbloquea-lo, todavia, ainda foi possível copiar por meio de foto uma anotação em bloco de notas onde continha intensa e várias anotações de quantidade e valor,

certamente uma contabilidade do tráfico, onde fica nítido que é decorrente de negociação com traficantes e usuários, há que deixar consignado a enorme quantidade de droga ali descrita.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia então ao constatado pela perícia no celular apreendido de propriedade de Rafael (fls. 38/79), com a apreensão do aparelho Apple A2105 (iPhone XR) com usuário vinculado ao Facebook: SEM USUÁRIO VINCULADO e número vinculado ao WhatsApp: APLICATIVO BLOQUEADO(fl. 40), porém, desse telefone, foi possível acessar anotação em bloco de notas, conforme já explanado alhures, bem como outro aparelho celular Samsung SM-G9650/DS (fl. 43), Conta de e-mail vinculada:

rangel_biólogo@hotmail.com, Número vinculado ao WhatsApp: +5518996292558 ~ Vini de propriedade de Marcos Vinicius Rodrigues Rangel, que foi apreendido em janeiro, e demonstrou que o réu venderia a ele 5 gramas de cocaína por R\$ 250,00, tendo um comprovante de pagamento feito por meio de pix para a conta de Rafael Dornelas por Marcos Vinicius. Também foi apreendido outro aparelho celular Marca: Samsung SM-A205G. Conta de e-mail vinculada: moratocesario1993@gmail.com. Usuário vinculado ao Facebook: ID: 100050270678864 ~ Vitor Morety (vitor.morety) Número vinculado ao WhatsApp: +5518997777562 ~ Morato, de propriedade de Vitor Morato (fl. 51), onde constou intensa negociação sobre drogas Vitor Morato e o réu Rafael Dornelas, sendo que Morato é conhecido da Polícia por ser grande distribuidor de drogas na cidade vizinha de Pirapozinho e conforme se vê as fls. 58, em um diálogo travado entre os dois, Morato pede a Rafael "Cica" que "separe 25 de pé ae" e Rafael prontamente diz "Me dá um salve quanto tiver por aqui".

No celular de Rafael Dornelas, também apreendido nos autos (fl. 58) consta ser um Samsung Modelo: SM-J701MT Conta de e-mail vinculada: luanaamelloo17@gmail.com

luuhmello_17@hotmail.com, usuário vinculado ao Instagram: ID: 335298794 ~ 'luuh (luanamelloo_) Usuário vinculado ao Facebook: ID: 100004111834175 ~ Luana Mello (luana.mello.581525) ID: 1052343998245985 ~ Luana Mello, Número vinculado ao WhatsApp: 5518996962493 ~ Ze Do Cavalo, denota-se que o celular pertence ao réu, embora consta contas vinculadas em nome da esposa, Luana Mello, onde foi encontrado farto material relacionado ao tráfico de drogas, principalmente entre Rafael "Zé do Cavalo" e Morato, da cidade de Pirapozinho.

No referido laudo, também consta fotos de pessoas manuseando droga, grande quantia em dinheiro, tijolos de droga sendo pesado, e o que chama atenção, principalmente, é um diálogo travado entre o réu e uma pessoa não identificada, onde segundo o relatório da Polícia Civil na conversa o interlocutor não identificado se identifica como "amigo do boy" e pergunta de Rafael conversou com "Boy" o qual afirma que sim, porém não entrou em detalhes como data e quantidade. O interlocutor afirma que "o rapaz vai vir de Osvaldo Cruz" até a hora do almoço e "vai leva 20". Rafael afirma que "não consegue tirar lá aonde está" porque tem gente lá e que "só a noite consigo desenterrar", "tá enterrado", portanto, é nítida a utilização da chácara, que segundo o réu, pertence a seu pai, mas ele que a utiliza para suas festas, e agora, evidencia que lá também é utilizada para guardar grande quantidade de drogas, onde a partir dali, pulveriza para outras traficantes menores, inclusive para Morato, que já conhecido nos meios policiais por ser traficante na cidade de Pirapozinho.

Observo que este último celular pertence ao réu Rafael, e que as fls. 71/75, Rafael trava diálogo também de grande interesse com pessoa de codinome "Vareja Amigo", que segundo relatório de investigações policiais (fl. 94), o número referente a esta pessoa é (18) 98828-3704, cadastrado em nome de Johnny Gabriel Pereira, contudo esse número de celular tem Chave Pix conforme demonstrado abaixo, cadastrada em nome de GUILHERME AUGUSTO GASQUES DA SILVA, CPF 423.729.978-31, que já teve passagens por tráfico de entorpecentes, e com ele, a negociação de compra e venda e entrega de droga é vultosa, além de um comprovante de pagamento via Pix de Guilherme Augusto Gasques para Rafael Silva Dornelas no valor de R\$ 1.000,00, o teor da conversa evidencia que Rafael Dornelas é quem fornece as drogas, tanto maconha, que por vezes tratam como chá, como cocaína para Guilherme, que por sua vez distribui para usuários finais, por isso foi nomeado como "Vareja", por certo, pela quantidade expressiva de drogas que Rafael repassa para ele.

A par de tudo isso, no aparelho celular também foi encontrada fotos de drogas, grande quantidade de dinheiro, armas e munições e que foram tiradas do próprio celular do réu, traziam em seu metadados, informações do aparelho que produziu a foto e a geolocalização de onde foi tirada a foto, onde o réu aparece com grande quantidade de dinheiro, incompatível com seu meio de vida, não demonstrou que trabalha nem sua renda, apenas dizendo que voltou a trabalhar com esquadrinhas na empresa Metal Master, situação típica de quem se exibi com o lucro fácil do comércio de drogas, e portanto, evidencia com grande eloquência nos autos a participação direta do réu no comércio espúrio de drogas.

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava na residência e na chácara de seu genitor, de onde retirava parte para a venda a terceiro, enquanto a maior parte ficava escondida na residência e na chácara, enterrada ou escondida nos meandros da residência.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência e ainda, mantinha em depósito e guardava mais drogas na chácara, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de

concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de manter em depósito e guardar a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Da mesma forma não prospera a alegação da acusação bis in idem, dizendo que o réu respondeu por esta acusação, ou seja, pela droga encontrada na chácara, na primeira oportunidade em que fora preso, porém, os fatos demonstram ao contrário, que o réu após sair da prisão, responder o processo em liberdade, ser condenado, ainda que de forma indefinida, sem trânsito em julgado, voltou a cometer os mesmos fatos, continuando na prática do comércio espúrio de drogas, ainda com maior intensidade e desenvoltura, expandindo os negócios para cidades circunvizinhas onde tem distribuidores que comprem bastante quantidade do réu.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e, de rigor, a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua Folha de Antecedentes Criminais e Certidão Estadual de Distribuição de Processos de fls. 127/131, que já foi condenado recentemente por crime de tráfico de drogas, pois, pouco tempo depois veio a ser novamente processado por idêntico crime.

Nesse caso, não é ele reincidente e nem essas condenações por falta de trânsito em julgado pode ser levada em consideração para configurar Maus antecedentes ou impedir o redutor previsto no artigo 33, §4º, do Código Penal, conforme julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18/8/2022, nos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, processos-paradigmas do Tema n. 1139 - Tráfico - Privilegiado - Inquéritos - Ações - Penais - Andamento, com a seguinte tese:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a

dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme

reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]". (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]". (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]". (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas apreendida em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os